

1500101-58.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... gramas de crack, para fins de tráfico.

Ainda, segundo a exordial o acusado, no dia 23 de janeiro de 2022, à noite, na Rua Maria Aparecida Salgueiro Garcia, número 2-110, no bairro Fortunato, neste comarca de Bauru-SP, o réu foi surpreendido com mais 43,81 gramas de crack, para fins de tráfico.

Também, segundo a inicial, o acusado, nas mesmas circunstâncias de tempo e local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500101-58.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500101-58.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2020413/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 22595878 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 875/22/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2020413 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2020413 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 875/22/050 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FELIPE DA SILVA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Lucas Felipe da Silva Costa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, da lei 11.343/06, em concurso material com o artigo 2º, caput, da Lei 12.683/12, c.c. artigo 1º, caput, da Lei 9.613/06, em concurso

material com o artigo 12, caput, da Lei 10.826/03.

Segundo a denúncia o acusado, no dia 23 de janeiro de 2022, às 21h, na Rua Domingos Oliva, quadra 1, no bairro Primavera, na cidade de Bauru, foi surpreendido com 105,65 gramas de crack, para fins de tráfico.

Ainda, segundo a exordial o acusado, no dia 23 de janeiro de 2022, à noite, na Rua Maria Aparecida Salgueiro Garcia, número 2-110, no bairro Fortunato, neste comarca de Bauru-SP, o réu foi surpreendido com mais 43,81 gramas de crack, para fins de tráfico.

Também, segundo a inicial, o acusado, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, possuía 3 munições, sendo duas calibre 0.38 e uma calibre 0.32, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, de acordo com a inaugural, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, mantinha consigo, no interior de sua residência, a quantia de 3.384 reais em cédulas, ocultando a movimentação dos valores provenientes do tráfico de drogas.

Boletim de ocorrência (fls. 47/52), auto de exibição/apreensão (fls. 54/55), laudo de constatação preliminar (fls. 57/66), laudo definitivo (fls. 141/145), laudo dos projéteis (fls. 146/151), laudo da faca e balança (fls. 159/163).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise da formalidade do ato (fls. 101/102), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 130/133, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

Foi ofertada resposta à acusação (fls. 233).

Na decisão de fls. 234/235, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 277/279 foram ouvidas as testemunhas Jonathan William de Oliveira, Matheus Henrique dos Santos, Larissa Caroline Dias, Luciana Aparecida da Costa Dias. Na mesma ocasião, foi restituído o veículo apreendido à testemunha Jonathan, sendo que o Parquet insistiu na oitiva dos milicianos ausentes.

Na audiência em continuação de fls. 342/343, foram ouvidos os policiais militares Luis Felipe Babine e Danilo Ribeiro Brandão e interrogado o acusado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 349/357 pugnando, em suma, pela parcial procedência da pretensão punitiva, absolvendo-se o acusado pelo delito de "lavagem de capitais", com condenação pelo tráfico de drogas, com a valoração do art. 42 da Lei nº 11.343/06, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa e a agravante do "estado pandêmico", com o afastamento do "tráfico privilegiado", e a fixação do regime inicial fechado.

Já a D. Defesa Constituída às fls. 359/365 pleiteou, em síntese, pela absolvição quanto ao delito de "lavagem de capitais", e posse de munições, este em razão da insignificância, pela quantidade de projéteis apreendidos, destituídos de arma, a valoração do "tráfico privilegiado", e a da atenuante da menoridade relativa, afastando-se a agravante do "estado pandêmico".

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

Ocorre que o crime de lavagem de capitais não restou demonstrado.

Eis a redação do dispositivo, contido no art. 1º "caput" da Lei nº 9.613/98: Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

No caso concreto, o dinheiro estava escondido (ocultado) na residência do acusado. E, o numerário não teve a origem elucidada.

Entretanto, somente isso não basta.

Com efeito, a ocultação consiste em apenas uma das fases da infração penal, sendo que, o elemento anímico (dolo) deveria ser voltado à perfectibilização das demais fases, isto é, dissimular e reinserir o montante na economia formal, o que não restou observado na espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO SUBSUNÇÃO DA CONDUTA DELIMITADA NO ACÓRDÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ABSOLVER A AGRAVANTE.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente contrariado na instância ordinária caracteriza deficiência na fundamentação, o que dificulta a compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.

2. Os tribunais têm competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre coação ilegal ao seu direito de locomoção.

3. Ainda que a mera ocultação, identificada como a primeira fase do ciclo de lavagem de dinheiro, caracterize o crime descrito no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, porquanto o tipo penal não exige, para a sua consumação, as demais etapas para dissimular e reinserir os ativos na economia formal, a conduta, para ser reconhecida como típica, deve estar acompanhada de um elemento subjetivo específico, qual seja, a finalidade de emprestar aparência de licitude aos valores ocultados, em preparação para as fases seguintes, denominadas dissimulação e reintegração.

4. Deve ser reconhecida, de ofício, a impossibilidade de subsunção da conduta atribuída à agravante - receber depósito bancário de R\$ 45,00 de integrante de associação para o tráfico de drogas - ao tipo penal relacionado ao crime de lavagem de capitais, quando tanto a sentença condenatória quando o acórdão recorrido deixam de indicar, minimamente, o intuito da ré de dissimular a origem ilícita do valor recebido ou, ao menos, a aceitação do risco de produzir tal resultado.

5. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido, de ofício, para absolver a agravante, por não constituir o fato crime de lavagem de dinheiro.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 328229 / SP, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 15/12/2015, g.n.)

Portanto, no ponto, de se invocar o secular in dubio pro reo, absolvendo-se o acusado, por falha no arcabouço probatório, apenas no que tange à mencionada infração penal.

Sob outro vértice, no tocante aos delitos de tráfico de drogas e posse de munições, ressalte-se que a materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 47/52), auto de exibição/apreensão (fls. 54/55), laudo de constatação preliminar (fls. 57/66), laudo definitivo (fls. 141/145), laudo dos projéteis (fls. 146/151), laudo da faca e balança (fls. 159/163).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares Danilo Ribeiro Brandão e Luiz Felipe Babine, na fase judicial (mídia SAJ), em síntese, disseram que receberam diversas informações acerca do comércio de drogas em um "pancadão", baile 'funk', próximo ao cemitério 'Cristo Rei', inclusive com disparo de arma de fogo. Afirmaram que a viatura do BAEP passou a realizar ronda pelo local, e, posteriormente, foi abordado um automóvel Focus, sendo encontrado, com o passageiro do banco traseiro, o réu, seis porções de 'crack', além de cerca de R\$ 800,00, sendo que ele informou que havia vendido os entorpecentes no baile 'funk'. Declinaram que foram até a residência do acusado, onde estaria a amásia dele, pois o próprio réu confirmou que havia mais droga e dinheiro naquele local. Esclareceram que, em diligências no imóvel, avistaram Luana, amásia do acusado que, imediatamente, informou que sabia do tráfico por parte do acusado, mostrando R\$ 334,00 que estava em sua bolsa, que teria sido entregue a ela por um adolescente. Mencionaram que ela não soube informar a procedência daquele dinheiro. Afirmaram que em seguida, chegaram a mãe e irmã de Luana, que passaram a acompanhar as buscas pelo imóvel. Citaram que a própria Luana, após autorizar o ingresso na residência, mostrou uma caixa de sapato, que estava no armário da cozinha, contendo balança de precisão, faca, rolo de papel filme e duas porções médias 'de crack'. Sobre o guarda-roupa, havia mais de R\$ 2500,00 em notas diversas; em cima da cama um caderno com anotações sobre o

comércio de drogas; e em um balcão entre a cozinha e a sala, duas munições de revólver .38 e uma munição de revólver calibre .32.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

A testemunha Jonathan William de Oliveira, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), em resumo, disse que é conhecido do acusado e que estava em uma festa com ele e Mateus. Afirmou que, ao sair da festa, deu carona para o réu e para Mateus, momento em que foram abordados pelos policiais. Informou que os policiais disseram que havia drogas em seu veículo, embora não tivesse visto nenhum entorpecente no local. Esclareceu que havia uma bolsa, mas não soube de quem era.

A testemunha Mateus Henrique dos Santos, sob o devido processo legal (mídia SAJ), em resumo, disse que estava em uma festa no bairro Nova Esperança, com o acusado. Afirmou que, ao saírem, pegaram carona com Jonathan, momento em que foram abordados por policiais. Informou que, enquanto eram revistados, chegou outra viatura.

Esclareceu que, em seguida, os policiais disseram que tinham encontrado drogas com o réu, entretanto, estava o tempo todo com o acusado e ele não carregava nenhuma bolsa. Mencionou que foi encontrado dinheiro que pertenceria a Jonathan, condutor do veículo.

A informante Larissa Caroline Dias, em juízo (mídia SAJ), disse que é cunhada do réu e, por isso, foi ouvida na condição de informante. Disse que estava na residência do acusado, quando a polícia chegou. Afirmou que autorizou a entrada dos policiais, mostrando a eles os cômodos e acompanhando as buscas. Informou que sua irmã mostrou uma caixa de sapato, que estava no guarda-roupa, mas os policiais a pegaram e saíram do local, não sabendo o que havia dentro dela.

A testemunha Luciana Aparecida da Costa Dias, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que é sogra do acusado e também estava na residência do acusado, quando a polícia apareceu. Afirmou que acompanhou as buscas pelo imóvel, até que os policiais encontraram uma caixa contendo dinheiro. Informou que foram

encontradas drogas e um balança de precisão no local.

O acusado Lucas Felipe da Silva Costa sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) confessou a prática do crime. Disse, em resumo, que estava com Mateus, quando pegaram carona com Jonathan, num veículo Focus. Afirmou que foram abordados pela polícia, sendo que, imediatamente, confessou a eles a posse de entorpecentes. Informou que outra equipe da polícia foi até sua casa e encontrou mais entorpecente, além das munições, que pertenciam a ele.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas e posse de munições.

O acusado confessou o delito.

E tal atenuante encontra amparo no restante da prova colhida.

Os policiais elucidaram como ocorreu a abordagem, primeiramente em um veículo.

Depois, outra equipe de milicianos - com autorização - encontraram mais drogas, todas compatíveis entre si (natureza 'crack').

Ainda no imóvel, foi apreendido dinheiro, aproximadamente, R\$ 3.384,00 sem procedência evidenciada.

No aspecto, importante citar que, conforme consta do pregressamento (fls. 19), o acusado auferia cerca de R\$ 1.600 mensais, como ajudante de pintor, sendo que a companheira, à época, estava grávida de 8 meses.

Além disso, também, no domicílio, foram apreendidos balança de precisão e faca, ambas com resquícios de entorpecentes.

De outro lado, também evidenciada a infração penal de posse de munições.

De início, importante citar que o laudo pericial atestou a lesividade das munições.

Por isso, a "perigo abstrato" transmudou-se, em ratificação, em "perigo concreto".

Depois, não se pode falar em bagatela própria.

No caso concreto, foram apreendidas três munições (duas .38 e uma .32, todas intactas).

Por isso, de se invocar o item 11, da edição nº 102 da Ferramenta "Jurisprudência em Teses" do Preclaro Superior Tribunal de Justiça: 11) A simples conduta de possuir ou de portar arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelos delitos previstos nos arts. 12, caput, da Lei 10.826/03 em concurso material com o art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Sob outro aspecto, deve o acusado Lucas permanecer custodiado.

A natureza do entorpecente - crack - conforme adiante se verá é perniciosa.

Além disso, às fls. 89, Lucas é responsabilizado pelos delitos de receptação e direção de veículo sem permissão - feito nº 1501443-41.2021.8.26.0594 -, cuja data do fato é 23/12/2021, isto é, apenas cerca de um mês antes dos fatos aqui delineados.

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este chancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material),

afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a

imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Tráfico de Drogas

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (crack), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto por que, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco

evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, o acusado confessou o delito e possui a menoridade relativa em seu favor.

Por isso, a pena deve retornar ao mínimo, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ainda na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado possui vasto "histórico" na Seara Infracional (fls. 90/91).

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE. MODO INTERMEDIÁRIO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

3. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na variedade dos entorpecentes apreendidos - 81,5g maconha e 30,7g cocaína -, na própria confissão do agente e nos registros de atos infracionais análogos aos delitos de homicídio e de furto que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 447045 / SP, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 07/08/2018).

Além disso, como dito, possui anotação anterior, sendo que, também, a quantidade de dinheiro e petrechos apreendidos (rolo plástico, caderno, balança) denotam que o acusado já se dedicava há algum tempo ao comércio espúrio e, portanto, às atividades criminosas.

Por isso, a pena atingida na segunda fase é a definitiva.

Posse de munições

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a reprimenda deve permanecer no piso, ou seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado confessou o delito e possui a menoridade relativa em seu favor.

Entretanto, nos moldes da Súmula nº 231 do STJ, sem modificação.

Ainda na intermediária, como mencionado, pela ausência de nexos de causalidade não pode ser valorada a agravante do "estado pandêmico".

Na final, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a pena é definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, tendo em vista que o acusado auferia cerca de R\$ 1.600 mensais.

Os bens jurídicos lesados são diversos, portanto de rigor o reconhecimento do concurso material, sem o efeito da soma das penas, em razão da natureza diversa das reprimendas.

Fixo o regime inicial fechado para o delito de tráfico.

O réu Lucas possui preocupante "passado" na Seara da Infância e Juventude.

Depois, cometeu receptação anterior e efetivamente realizava o comércio espúrio, e "preparava" o entorpecente em sua casa.

Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido

de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme

dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

Em relação ao delito de posse de munições, tendo em vista que a pena-base foi inteiramente favorável, e que não há notícias que os artefatos foram efetivamente utilizados (tanto que não havia qualquer arma compatível), fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c" e §3º do Código Penal.

No ponto, o concurso material de delitos, impede a substituição por restritivas de direitos, pela insuficiência, nos moldes do art. 44, III do Digesto Material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL deduzida na ação penal, e, desta maneira:

ABSOLVO O ACUSADO LUCAS FELIPE DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, outrora responsabilizado pelas infrações descritas no artigo 2º, caput, da Lei 12.683/12, c.c. artigo 1º, caput, da Lei 9.613/98, com fulcro no art. 386, VII do CPP;

CONDENO O ACUSADO LUCAS FELIPE DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06;

CONDENO O ACUSADO LUCAS FELIPE DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 12 "caput" da Lei nº 10.826/03.

Nego ao acusado Lucas o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 33/34. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto aos aparelhos celulares, balança, sacos plásticos, faca, cadernos e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Determino a destruição das munições apreendidas, nos termos do art. 25 "caput" da Lei nº 10.826/03.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA